

1502154-74.2021.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... c.c 303 do CPP). No mais, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se protraí no tempo e permite a prisão em flagrante a qualquer momento.

Nesse sentido, ainda, é o entendimento fixado pelo E. TJSP em recentíssimos julgados:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. Preliminares. Crime permanente indicando situação de flagrância apta a autorizar a pronta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502154-74.2021.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502154-74.2021.8.26.0132

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2190579/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 19045926 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

3308/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2190579 - DEL.INV.GER. CATANDUVA,

3308/21/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIA EDUARDA MESSIAS DOS SANTOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Gesiel Maiores dos Santos, Renan Garcia Gonzaga e Maria Eduarda Messias dos Santos dando-os como incursos nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, em razão dos fatos assim descritos (fls.

124/126):

Consta no incluso inquérito policial que, no dia 14 de junho de 2021, em horário incerto, na Rua das Lichias, 188, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, GESIEL MAIORES DOS SANTOS, RENAN GARCIA GONZAGA E MARIA EDUARDA MESSIAS DOS SANTOS, qualificados à fl. 16/20, guardavam drogas, consistentes em 55 (cinquenta e cinco) tijolos de maconha para fins de comércio ilícito com terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 29/31.

[...]

Policiais militares estavam em patrulhamento, oportunidade em que receberam uma denúncia no sentido de que no endereço dos denunciados Renan e Maria Eduarda, havia uma grande quantidade de drogas guardada, bem como na loja de piscina de propriedade de Gesiel.

Em posse de tal informação, dirigiram-se até o local indicado, sendo que lá se encontrava apenas a denunciada Maria Eduarda. Indagada, ela disse que apenas guardava uma pequena porção de maconha para seu consumo pessoal.

Ao revistar a residência, foram localizadas, embaixo de um sofá, 49 tijolos de maconha, bem como vários sacos plásticos e uma balança de precisão.

Indagada, a denunciada confessou que ela e o denunciado Renan guardavam as drogas em troca de R\$500,00 (quinhentos) reais por semana e que, na loja de piscinas onde Renan trabalhava, denominada Água Azul, de propriedade do denunciado Jesiel, haveria mais uma quantidade do entorpecente escondido. Ato contínuo, ao diligenciar pelo local, nos fundos do imóvel, foram localizados 6 (seis) tijolos de maconha.

[...]

A prisão em flagrante da acusada Maria Eduarda Messias dos Santos foi convertida em preventiva em 15 de julho de 2021 (fls. 58/63). Já a prisão cautelar dos corréus Renan Garcia Gonzaga e Gesiel Maiores dos Santos foi decretada em 17 de agosto de 2021 (fls. 127/230), sendo que este permaneceu foragido e aquele foi preso em 24 de agosto de 2021 (fls. 151/153).

Notificados (fls. 150, 165 e 241), os acusados apresentaram defesa preliminar (fls. 191/212, 241/247 e 264/285) e a denúncia foi recebida em 18 de novembro de 2021 (fl. 319).

No curso da instrução criminal foram ouvidas sete testemunhas e um informante, decretada a revelia do acusado Gesiel e interrogado os corréus Maria Eduarda e Renan, sendo que este confessou a prática ilícita, ao passo que aquela refutou qualquer envolvimento com a traficância de drogas.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram.

Em alegações finais, o Ministério Público requer a parcial procedência da pretensão punitiva estatal tão somente para condenar o acusado Renan (fls. 545/552), com o que concordou a Defesa do imputado Gesiel (fl. 556). Já a Defesa dos acusados Renan e Maria Eduarda, preliminarmente, invoca a ilicitude das provas obtidas em virtude da violação domiciliar e, no mérito, pleiteia a absolvição (fls. 557/565).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Antes de ingressar no mérito da demanda, é de rigor a análise da questão preliminar ventilada pela Defesa atinente à violação do domicílio dos acusados Renan e Maria Eduarda, cuja rejeição se impõe.

Sobre o assunto, não se olvida que o Supremo Tribunal Federal, em decisão paradigmática, dotada de repercussão geral, fixou parâmetros para que seja considerada válida a entrada em domicílio sem mandado judicial:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.

Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori.

Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da

Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) - GRIFEI

Destarte, de acordo com a decisão colacionada, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas "a posteriori", que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. In casu, a ação policial se adequou ao decidido pelo STF. Isso porque os policiais militares, de posse de prévia notícia de que na localidade em que se desenvolveu a ação havia armazenamento de substâncias entorpecentes, diligenciaram e realizaram a abordagem da acusada Maria Eduarda, a qual teria admitido possuir drogas para seu consumo pessoal e autorizado o ingresso policial. Já no interior da residência foi encontrada a farta quantidade de entorpecentes.

Destarte, a diligência inicial, lícita resultou na apreensão de tijolos de maconha, hábil a configurar a situação flagrancial (art. 302, I c.c 303 do CPP). No mais, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se protraí no tempo e permite a prisão em flagrante a qualquer momento.

Nesse sentido, ainda, é o entendimento fixado pelo E. TJSP em recentíssimos julgados:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. Preliminares. Crime permanente indicando situação de flagrância apta a autorizar a pronta ação da Polícia, independentemente de mandado, sem se desprezar o fato de o corréu E. haver franqueado o acesso dos policiais ao imóvel. Inteligência dos artigos 5º, XI, da Constituição Federal e 150, § 3º, II, do Código Penal. Inexistência de ofensa ao princípio da correlação diante do pedido de absolvição formulado pelo Promotor de Justiça em alegações finais. Nulidade inexistente. Matérias rejeitadas. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão parcial do corréu E. Relatos seguros e coesos dos policiais militares, que apreenderam considerável quantidade de droga e apetrechos relacionados ao espúrio comércio. Delito que admite coautoria ou participação. Condenação mantida. Penas-base acima do piso em face de circunstâncias desfavoráveis representadas por antecedentes desabonadores com relação ao corréu R. e acentuada culpabilidade (artigo 42 da Lei de Drogas). Multirreincidência de R., corrigido erro material representado por apontamento de uma das condenações pretéritas atinente à agravante em pauta. Quadro negativo inconciliável com o privilégio descrito no artigo 33, § 4º, daquela mesma Lei Extravagante, a par de obstaculizar a substituição das corporais por restritivas de direitos providência também colidente com o montante das penas. Regime prisional fechado único adequado ao crime de natureza hedionda, sem se ignorar a existência de circunstâncias adversas e a recidiva de R. igualmente incompatíveis com retiro menos severo. Recursos improvidos, com correção de erro material. (Apelação Criminal nº 1501431-93.2019.8.26.0530, Sertãozinho, rel. Farto Salles, j. 24/06/2021).

APELAÇÃO. Atos infracionais equiparados aos crimes previstos no artigo 33, caput, e 35, c.c. 40, inciso VI, todos da lei n. 11.343/2006. Inexistência de nulidade na ação policial, porque acobertada por hipótese expressamente permitida pelo inciso XI, do artigo 5º, da Constituição Federal. Diante da situação fática-probatória dos

autos, verifica-se que não se tratou de mera intuição dos policiais, uma vez que havia elementos que caracterizavam a suspeita de flagrante delito no interior do domicílio. Sentença que, ao contrário do alegado nas razões recursais, apresenta fundamentação idônea, baseada em análise acurada da prova dos autos. Recurso ao qual se nega provimento. (TJSP; Apelação Cível 1500280-40.2020.8.26.0439; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Pereira Barreto - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020)

"Habeas corpus" - Tráfico de drogas - Alegação de que as provas foram obtidas ilicitamente, mediante violação de domicílio - Pedido de concessão de ordem para trancar a ação penal e nulificar o feito, com a consequente soltura do paciente - Não acolhimento - Ausência de constrangimento ilegal - Inteligência do art. 5º, XI, da CF, que dispensa consentimento do morador e ordem judicial para o ingresso em domicílio alheio nos casos de "flagrante delito" - Tráfico de drogas nas modalidades "guardar" e "ter em depósito" - Crime permanente - Possível a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência (art. 303, CPP) - Existência de fundadas razões a justificar o ingresso dos policiais na residência do paciente - Precedentes - Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2057567-23.2021.8.26.0000; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento: 08/04/2021; Data de Registro: 08/04/2021)

De mais a mais, a Defesa almeja mediante a alegação da questão preliminar, há de se convir, tornar inválida apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes que, de acordo com o próprio acusado, são provenientes do e destinados ao tráfico de drogas - em manifesta inversão da ordem lógica e de Justiça.

Não se vislumbra, portanto, afronta ao disposto no art. 5º, XI, da CF, e aos paradigmas fixados pelos Tribunais Superiores no tocante ao ingresso em domicílio sem mandado.

Nem se argumente, ademais, que a diligência é nula em virtude da ausência de autorização por escrito do réu ou da filmagem da ação policial. Isso porque os standards probatórios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo dos HC's 616.584/RS e 598051/SP foram anulados pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1342077, interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.

Assim, em sede de preliminar e sem embargo da reapreciação no capítulo seguinte, é de rigor afastar as alegações de nulidade da prova coletada e de aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. O conjunto de elementos informativos e probatórios carreado nos autos - formado pela prova oral amealhada e pela apreensão das drogas - é válido e hábil a formar o convencimento do julgador.

Destarte, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito.

Trata-se de ação penal pela qual o Ministério Público imputa ao réu Gesiel Maiores dos Santos, Renan Garcia Gonzaga e Maria Eduarda Messias dos Santos a infração penal prevista no art. 33 da Lei 11.343/06.

Diante do arcabouço probatório produzido, a pretensão punitiva deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11) pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), pelos laudos de constatação provisória e definitiva de substância entorpecente (fls. 29/31 e 483/485) e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

Já no tocante à autoria, é de se ver que ao cabo da instrução criminal o Ministério Público pugnou pela absolvição dos imputados Gesiel Maiores dos Santos e Maria Eduarda Messias dos Santos porquanto não vislumbrou provas suficientes para a condenação.

Bem verdade que o art. 385 do CPP possibilita ao julgador proferir sentença condenatória apesar do pleito absolutório do titular da ação penal. Entretanto, diante do sistema acusatório constitucional (art. 129, I, da CF) e legalmente (art. 3º-A do CPP) vigente em nosso ordenamento jurídico, reputo o dispositivo inconstitucional, de modo que se torna descabida maior análise da matéria.

Destarte, quanto aos acusados Gesiel Maiores dos Santos e Maria Eduarda Messias dos

Santos, o decreto absolutório, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, é medida de rigor.

Em contrapartida, com relação ao acusado Renan Garcia Gonzaga, não obstante a argumentação trazida pela combatente Defesa, a condenação é medida a ser imposta. Com efeito, o policial militar Fábio de Moraes Duarte, em Juízo, declarou que com prévias informações acerca do armazenamento de drogas para fins de comercialização, diligenciou até a residência onde foram apreendidas as drogas e encontraram a acusada Maria Eduarda, que foi submetida à abordagem. Contou que com a anuência da referida imputada, a qual admitiu possuir drogas para seu consumo pessoal, ingressou no interior do imóvel e logrou encontrar embaixo de um sofá o total de quarenta e nove tijolos de maconha. Respondeu que foi informado por Maria Eduarda de que mais drogas eram escondidas em outros endereços, dentre os quais na loja de Gesiel, indivíduo já conhecido pela traficância, onde os policiais apreenderam mais maconha.

Na mesma linha foram as declarações do policial militar Célio Victor da Mota, o qual confirmou a obtenção de informe acerca da traficância de drogas no endereço do réu, a abordagem da acusada Maria Eduarda, a apreensão de tijolos de maconha no interior do sofá da residência e o recolhimento de drogas na loja de piscinas que seria de Gesiel.

As testemunhas Camiliane de Oliveira Perini, Joice Fernanda Oliveira, Rafael Augusto Venâncio, Bárbara Maria Gonçalves Casal e o informante José Paulo Gonzaga, todos arrolados pelas Defesas, declararam, em síntese, que a acusada Maria Eduarda estava no interior de sua residência quando da chegada dos policiais, os quais teriam impedido o acesso de terceiros ao imóvel, inclusive da advogada dos réus. Disseram, também, que Renan presta serviços atinentes à manutenção de piscinas e possui uma loja de produtos relacionados.

Por ocasião de seu interrogatório, a imputada Maria Eduarda Messias dos Santos negou o envolvimento com a traficância de drogas. Disse não ter autorizado o ingresso de policiais em seu domicílio, mas confirmou que no local foram apreendidos quarenta e nove tijolos de maconha, os quais estariam sendo guardados por seu namorado e corréu Renan. Rechaçou ter conhecimento de que Gesiel atua na traficância de drogas. Respondeu que as declarações que prestou em sede policial são viciadas, pois manipuladas pelos agentes públicos.

Já Renan Garcia Gonzaga, quando interrogado, admitiu que guardava as substâncias entorpecentes e percebia, pelo serviço, R\$ 500,00 (quinhentos reais) por semana. Não quis identificar para quem guardava as drogas, mas refutou o envolvimento de Gesiel no ilícito, assim como de Maria Eduarda.

À toda evidência, a confissão firmada pelo acusado Renan se coaduna com as declarações da corré Maria Eduarda, com a apreensão das drogas em seu domicílio e com as narrativas dos policiais militares ouvidos como testemunhas, de modo que é inafastável a sua responsabilidade criminal.

Outra vez mais, e não obstante as declarações das testemunhas, não há se falar em ilegalidade frente à natureza permanente do tipo penal em apreço, da narrativa dos policiais militares e da ausência de provas seguras acerca da sustentada nulidade. Veja-se, no ponto, que a narrativa das testemunhas – conquanto tragam notícias de supostas violações a prerrogativas de profissional da advocacia – não servem para rechaçar a validade da prova. A tese de violação ilícita do domicílio, frise-se, não se sustenta. A uma, pela inverossimilhança ínsita à narrativa de que todas as testemunhas, curiosa e ocasionalmente, tenham presenciado a chegada dos policiais militares ao local. A duas, porque nada falam acerca do recolhimento de quilos de drogas – o que é fato incontroverso nos autos. A três, porque a acusada Maria Eduarda, durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, afirmou que autorizou o ingresso dos policiais em seu domicílio (fls. 06/07). E, a quatro, como já muitas vezes salientado, a consumação do crime em questão se protraí no tempo e possibilita a prisão em flagrante, como de fato ocorreu. Nesse sentido:

"Habeas corpus" – Tráfico de drogas – Alegação de que as provas foram obtidas ilicitamente, mediante violação de domicílio – Pedido de concessão de ordem para trancar a ação penal e nulificar o feito, com a consequente soltura do paciente – Não acolhimento – Ausência de constrangimento ilegal – Inteligência do art. 5º, XI,

da CF, que dispensa consentimento do morador e ordem judicial para o ingresso em domicílio alheio nos casos de "flagrante delito" - Tráfico de drogas nas modalidades "guardar" e "ter em depósito" - Crime permanente - Possível a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência (art. 303, CPP) - Existência de fundadas razões a justificar o ingresso dos policiais na residência do paciente - Precedentes - Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2057567-23.2021.8.26.0000; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento: 08/04/2021; Data de Registro: 08/04/2021)

Embargos de declaração - Omissão consistente na não apreciação do argumento de que teria havido violação de domicílio do agente por parte da Polícia - Acolhimento para refutar a tese - Flagrante em crime de natureza permanente Devem ser acolhidos os embargos de declaração apenas para sanar omissão, a fim de ser apreciada a alegação da violação de domicílio. Em havendo fundadas suspeitas da ocorrência de tráfico de entorpecentes, a situação de flagrância associada à natureza permanente do crime, afasta a ilegalidade de eventual ingresso não autorizado na residência do acusado pela Polícia, razão pela qual não se concebe ocorrência de violação de domicílio, ainda que os policiais tenham agido sem mandado judicial. A diligência deve ser considerada absolutamente lícita, sendo lícitas também as provas dela derivadas. (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0013788-97.2015.8.26.0344; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/06/2019; Data de Registro: 19/06/2019)

Destarte, inequívoca a existência da infração penal e sua autoria. Assim, quanto ao acusado Renan Garcia Gonzaga tem-se que tanto a existência quanto a autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 estão cabalmente comprovadas nos autos, não havendo se falar em insuficiência probatória ao decreto condenatório e aplicação do princípio do in dubio pro reo. A prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Na primeira fase, em análise ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 e no art. 59 do CP, conclui-se que conquanto natureza da substância entorpecente apreendida não revele anormalidade, a quantidade (aproximadamente cinquenta quilos) é elevada, incomum e deve ser reputada desfavorável. Todavia, deixo de valorá-la como tal a fim de evitar bis in idem, já que a circunstância será considerada na terceira fase de fixação da pena. Nesse sentido é a jurisprudência do C. STJ e do E. TJSP:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. VALORAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA DA PENA. OCORRÊNCIA. BIS IN IDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. [...] 2. Em consonância com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (ARE 666.334/MG, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJ 6/5/2014), o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que configura bis in idem a utilização da natureza e da quantidade de entorpecente, concomitantemente, na 1ª e na 3ª fases da dosimetria da pena. [...] (HC 329.744/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 26/11/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Réu que se conforma com a condenação e busca a redução da pena imposta; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; a aplicação de regime prisional mais brando; e, ainda, a restituição do automóvel apreendido - Pena redimensionada - Necessidade - Aumento levado a efeito na primeira etapa da dosimetria afastado, já que a quantidade de droga apreendida deve ser considerada apenas na terceira fase do cálculo dosimétrico, de forma a impedir a aplicação do redutor do § 4º, do artigo 33 da Lei Antidrogas, sob pena de 'bis in idem' - Incabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Perdimento do bem apreendido mantido - Recurso parcialmente provido, sem repercussão, no entanto, na pena final do réu. (TJSP; Apelação Criminal 1500411-

89.2019.8.26.0264; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itajobi - Vara Única; Data do Julgamento: 27/07/2020; Data de Registro: 27/07/2020)

No mais, a culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade do comportamento, é insita ao tipo penal. O réu não ostenta antecedentes. Não há notícias desfavoráveis acerca da conduta social e da personalidade do agente, motivo pelo qual tais circunstâncias são neutras. Os motivos do crime, assim como as circunstâncias, são próprios da espécie. As consequências do delito não foram apuradas. Não há comportamento de vítima a ser valorado. Logo, fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, à luz de sua qualificação, reconheço a confissão (art. 65, III, 'd', do CP), mas, como não há incidência de causas agravantes, deixo de valorá-la em virtude do teor da Súmula n. 231 do STJ, que impede a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal. Logo, mantenho a pena intermediária nos patamares da pena-base.

Na terceira e derradeira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento. Não merece acolhida a tese defensiva de aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, diante da elevadíssima quantidade de substância entorpecente, que não é comumente apreendida no município de Catanduva/SP, o qual não ostenta elevados índices de violência e criminalidade.

Ademais, além da quantia de entorpecentes, o caso apresenta outras peculiaridades hábeis a rechaçar a tese de que o acusado é "pequeno traficante", notadamente atinentes às prévias informações obtidas pelos policiais de sua atuação na comercialização de drogas e no armazenamento das substâncias em pontos distintos. Dessa forma, não faz o réu jus à causa de diminuição de pena em comento. Nesse sentido, vale registrar, é a posição do E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Réu que se conforma com a condenação e busca a redução da pena imposta; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; a aplicação de regime prisional mais brando; e, ainda, a restituição do automóvel apreendido - Pena redimensionada - Necessidade - Aumento levado a efeito na primeira etapa da dosimetria afastado, já que a quantidade de droga apreendida deve ser considerada apenas na terceira fase do cálculo dosimétrico, de forma a impedir a aplicação do redutor do § 4º, do artigo 33 da Lei Antidrogas, sob pena de 'bis in idem' - Incabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Perdimento do bem apreendido mantido - Recurso parcialmente provido, sem repercussão, no entanto, na pena final do réu. (TJSP; Apelação Criminal 1500411-

89.2019.8.26.0264; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itajobi - Vara Única; Data do Julgamento: 27/07/2020; Data de Registro: 27/07/2020)

Revisão criminal - Tráfico de entorpecentes - Modificação da reprimenda - Ocorrência de bis in idem na primeira e terceira fases da dosimetria - Aplicação do causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Modificação do regime prisional e possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Pena-base alterada, porquanto indevidos dois dos motivos que justificaram a sua exasperação - Bis in idem caracterizado - Redutor negado, em razão da quantidade de drogas apreendidas - Regime mantido, mercê da gravidade concreta da conduta - Inviável, por idênticos motivos, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Revisão parcialmente deferida, mas sem reflexo na reprimenda final. (TJSP; Revisão Criminal 2271760-93.2020.8.26.0000; Relator (a): Fernando Torres Garcia; Órgão Julgador: 7º Grupo de Direito Criminal; Foro de Itapevi - Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/02/2021; Data de Registro: 15/02/2021)

Destarte, fixo a pena definitiva do acusado Jefferson em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 43 da Lei 11.343/06 c.c art. 49, §1º, e 60 do CP), já que incerta a capacidade econômica do acusado.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, diante da circunstância judicial desfavorável e da gravidade em concreto da conduta, a qual era hábil a abastecer inúmeros pontos de venda de drogas e atingir um sem-número de populares, inclusive crianças e adolescentes – fatores que apontam a necessidade de maior repressão à atividade ilícita e obstam a aplicação de regime menos severo. Nesse sentido:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Acórdão do STJ que concedeu habeas corpus a fim de que esta C. Câmara proceda à nova dosimetria da pena, com a utilização da quantidade de drogas apreendidas em somente uma das etapas da dosimetria – Pena base redimensionada para o mínimo legal – Mantida a não aplicação do redutor em razão da quantidade e variedade dos entorpecentes encontrados – Regime inicial fechado mantido diante da gravidade dos fatos. (TJSP; Apelação Criminal 1500553-70.2020.8.26.0616; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

À luz da natureza da infração penal e da quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, inviável a sua substituição por restritivas de direitos ou a sua suspensão condicional (arts. 44 da Lei 11.343/06 e arts. 44, I, e 77 do CP).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ABSOLVER os acusados Maria Eduarda Messias dos Santos e Gesiel Maiores dos Santos da imputação da infração penal prevista no art. 33 da Lei 11.343/06, e para CONDENAR o acusado Renan Garcia Gonzaga como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06 à reprimenda de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época do fato.

Por se tratar de crime vago, não há se falar em fixação de valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Porquanto permanecem hígidos os cenários fático e jurídico que outrora ensejaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva do acusado Renan Garcia Gonzaga, mantenho-a. Com efeito, enquanto o *fumus commissi delicti* resta verificado em sede de cognição exauriente, o *periculum in libertatis* é extraído da gravidade em concreto das condutas do réu, cujos antecedentes indicam a habitualidade delituosa e a periculosidade social, o que inequivocamente ocasiona severo e concreto risco à ordem pública e indica que a libertação do agente lhe permitirá retornar ao seio propício à atividade de traficância. Logo, a segregação cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, motivo pelo qual, com fulcro no art. 387, §1º c.c 311, 312 e 313, I, do CPP, mantenho a prisão preventiva do acusado Samuel Soares Machado. Recomende-se à prisão.

Lado outro, em vista da improcedência da pretensão punitiva e do disposto no art. 386, parágrafo único, I, do CPP, REVOGO a prisão preventiva de Maria Eduarda Messias dos Santos e Gesiel Maiores dos Santos. Expeça-se alvará e o que mais for necessário.

Em observância ao art. 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das amostras de substância entorpecente guardadas para contraprova, com certificação nos autos. Quanto aos demais bens, eis que desprovidos de utilidade e valor econômico, autorizo a destruição.

Condeno o réu Renan Garcia Gonzaga, ainda, ao pagamento das custas processuais que lhe competem, nos termos do art. 804 do CPP. Entretanto, com base no art. 98, §3º, do CPC, c.c art. 3º, do CPP, suspendo a exigibilidade do encargo em vista da gratuidade de Justiça que ora confiro.

Com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da CF, intime-se o réu para pagamento da multa no prazo de dez dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP) e expeça-se as guias de execução.

P. I. C., com observância do disposto no art. 392 do CPP.

Catanduva, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA